

1501356-46.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração". (EResp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção)

Na hipótese dos autos, em consulta ao processo menorista, verifico que a condenação infracional por idêntico crime de tráfico de drogas transitou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501356-46.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501356-46.2022.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANI OLIVEIRA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 23 de julho de 2022, às 16h50min, na Rua Jorge Fadlo, 369, Parque Paraíso, cidade e comarca de Itapecerica da Serra, os réus GEOVANI OLIVEIRA SANTOS e LUCAS DOS SANTOS SANTANA, agindo consciente e voluntariamente, traziam consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 66 porções de crack, com peso líquido de 7g, 90 porções de maconha, com peso líquido de 120g, 80 porções de cocaína com peso líquido de 40g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, além da quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais), conforme laudo de constatação de fls. 18/20, auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e laudo toxicológico definitivo de fls. 125/126.

Denúncia recebida à fl. 167. As provas orais e os interrogatórios foram colhidos por meio audiovisual.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a ação é procedente.

A materialidade é expressa pelo laudo toxicológico de fls. 125/126, bem como toda a prova oral produzida.

Quanto à autoria, os réus admitiram a prática delitiva, em harmonia com o depoimento judicial do policial militar Gilvan.

A condenação é imperativa, portanto.

Passo a dosar as penas.

2. Início pelo réu Lucas.

Na primeira fase, não existe circunstância judicial desfavorável, a recomendar o aumento da pena-base. Isso porque, ao reverso do meu posicionamento, a atual jurisprudência do STJ não admite que a quantidade e natureza dos entorpecentes sejam ponderadas neste momento e na terceira etapa do critério trifásico.

Na segunda fase, nada a considerar.

Na terceira fase, encontra-se presente a majorante do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06.

Assim o é, porque o fato foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, cabendo destacar o depoimento em juízo do policial Gilvan, dando conta de que o colégio ficava a, no máximo, 60 metros de distância do local da prisão.

De todo irrelevante qualquer cogitação sobre a efetiva presença de discentes no momento da detenção dos réus, pois pacificado perante o STJ a compreensão no sentido de que a majorante em análise possui natureza formal ou objetiva, razão por que dispensada a concreta exposição do alunado à mercancia funesta. Assim:

“... ”

2. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica - como efetivamente tinha, no presente caso, ao que se colhe do acórdão (e-STJ, fl. 1.157). Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da instituição.

3. Agravo regimental desprovido”.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.854.478/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

“(...) 4. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância”. (STJ, HC nº 273.710/MS, Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, j. 18/06/2014.)

Quanto à calibragem do aumento, considerando que a quantidade de entorpecentes será valorada em seguida, de modo a evitar bis in idem contra o inculpaado majoro a exprobração no patamar mínimo de 1/6, estipulando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Por derradeiro, encontra-se presente a minorante contida no art. 33, par. 4º, pois o réu não ostenta antecedentes negativos ou outra circunstância que sugira se tratar de pessoa habitualmente dedicada à criminalidade (embora, a meu juízo, a quantidade dos narcóticos se prestasse a tal finalidade).

Vigora, atualmente, o posicionamento manifestado no REsp 1.887.511/SP, pelo qual se admite que a quantidade/qualidade de drogas seja valorada na modulação da causa de diminuição, desde que não o tenha sido nas fases anteriores. Assim (grifei):

"Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Diretrizes firmadas no EREsp 1.887.511/SP. Uso apenas supletivo da quantidade e natureza da droga na terceira fase da dosimetria. Revisão de posicionamento. Manutenção do entendimento consolidado há anos pelas Cortes Superiores, acolhido no ARE 666.334/AM pelo STF. Expressiva quantidade de droga apreendida. Único elemento aferido. Modulação da causa de diminuição. Possibilidade.

"É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena."

(HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022.)

Considerando a enorme quantidade de entorpecentes (236 porções de 3 tipos de drogas), representativa, senão de dedicação habitual ao comércio espúrio, ao menos de reprovabilidade acima do ordinário, entendo que o abrandamento deve montar no patamar mínimo de 1/6, de modo a reconduzir a admoestação ao patamar de largada (5 anos de reclusão).

Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da nova Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com a pena corporal aplicada, fixo o número de dias-multa em 500. Em um segundo momento, atento à condição financeira do réu, estipulo os dias-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à míngua de maiores informações.

Ao réu Geovani.

Tendo em vista a já mencionada quantidade de entorpecentes e, nos termos do sobredito REsp 1.887.511/SP, que tal elemento não será valorado na terceira etapa, elevo a pena-base neste momento em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Na segunda fase, recuo a censura à faixa de saída, diante das atenuantes da confissão e da menoridade relativa.

Na terceira fase, encontra-se presente a majorante do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06.

Assim o é, porque o fato foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, cabendo destacar o depoimento em juízo do policial Gilvan, dando conta de que o colégio ficava a, no máximo, 60 metros de distância do local da prisão.

De todo irrelevante qualquer cogitação sobre a efetiva presença de discentes no momento da detenção dos réus, pois pacificado perante o STJ a compreensão no sentido de que a majorante em análise possui natureza formal ou objetiva, razão por que dispensada a concreta exposição do alunado à mercancia funesta. Assim:

"...

2. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica - como efetivamente tinha, no presente caso, ao que se colhe do acórdão (e-STJ, fl. 1.157). Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da

instituição.

3. Agravo regimental desprovido".

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.854.478/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

"(...) 4. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância". (STJ, HC nº 273.710/MS, Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, j. 18/06/2014.)

Quanto à calibragem do aumento, considerando que a quantidade de entorpecentes foi valorada na primeira etapa, de modo a evitar bis in idem contra o inculcado majoro a exprobração no patamar mínimo de 1/6, estipulando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, o réu não faz jus à minorante do art. 33, par. 4º, da Lei de Drogas.

Com efeito, Geovani possui condenação definitiva por tráfico de drogas na infância (processo nº 0003344-29.2021.8.26.0268, informado à fl. 47).

O STJ fixou o entendimento de que a existência de condenação por ato infracional pode justificar o afastamento da minorante, desde que (i) por fato grave e (ii) revestida de proximidade temporal com o crime praticado na vida adulta. Assim:

"Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração". (EResp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção)

Na hipótese dos autos, em consulta ao processo menorista, verifico que a condenação infracional por idêntico crime de tráfico de drogas transitou em julgado no dia 13/09/2021, ou seja, menos de um ano antes do cometimento do corrente delito. Aliás, o réu estava cumprindo medida socioeducativa de liberdade assistida, quando da prisão em flagrante por este feito, extinta apenas em 26/09/2022 (já com o presente processo em andamento).

O fato de o inculcado, há pouco entrado na maioridade, ostentar passado maculado na seara infracional por idêntico malfeito configura marcador fortíssimo a autorizar a conclusão de que se trata de indivíduo devotado costumeiramente à mercancia funesta, não se tratando de traficante de "primeira viagem". É possível concluir, pois, que se trata de sujeito no curso de trajetória criminosa linear na perpetração de delitos graves, sem qualquer solução de continuidade entre a adolescência e a vida adulta, resultando infrutíferas as medidas socioeducativas aplicadas na Justiça Infracional.

Afastada a benesse, pois, havendo elementos bastantes de que o réu é pessoa aplicada à criminalidade.

Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da nova Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com a pena corporal aplicada, fixo o número de dias-multa em 583. Em um segundo momento, atento à condição financeira do réu, estipulo os dias-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à míngua de maiores informações.

3. Passo a deliberar sobre o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e sobre a possibilidade de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos.

Início pelo réu Geovani.

Mudando o meu posicionamento, passei a entender viável a imposição legal de início de cumprimento de pena em regime inicial fechado, independentemente de singularidades do caso concreto. Explico.

É verdade que o STF já considerou inconstitucional a determinação de regime inicial obrigatoriamente fechado (art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos), cabendo ao juiz do caso o estabelecimento do regime a partir da aferição dos elementos concretos do processo (HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012).

Todavia, não há decisão em tal sentido prolatada em sede de controle concentrado de constitucionalidade; logo, inexistente efeito vinculante a manietar os demais órgãos judiciários.

Ademais, o próprio STF, ao que parece, vem vacilando sobre o tema.

É que a 1ª Turma daquela Corte Constitucional reputou constitucional o art. 1º, par. 7º, da Lei n. 9455/97, que estabelece, como regra, cumprimento de pena em regime inicial fechado para os condenados pelo crime de tortura (HC 123316/SE, rel. Min. Marco Aurélio, 9.6.2015).

Vale ressaltar que a tortura e o tráfico de entorpecentes receberam o mesmo tratamento pelo constituinte originário (art. 5º, XLIII, CF/88).

Não há qualquer razão, portanto, para conferir ao condenado por tráfico tratamento mais benevolente do que o concedido ao apenado pelo delito de tortura -- sendo conveniente lembrar, aliás, que o crime de tortura, salvo quando resulte em morte da vítima, possui pena-base inferior ao de tráfico.

Enfim, deve ser homenageado o art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos.

De qualquer forma, ainda que fosse deixado de lado o dispositivo supra, é fato que qualquer outro regime não fará frente aos objetivos da prevenção e reprovação do crime (art. 59, caput, parte final, CP), em vista da gravidade em concreto do delito praticado, o que autorizou, destarte, o incremento da censura na primeira e terceira fases, além da negativa de diminuição na última etapa do trajeto censório.

Em acréscimo, reitero a argumentação atinente ao passado nodoso do réu, também como forma de fundamentar o regime inicial fechado, dada a trajetória criminosa em que incurso o apenado.

Sobre o réu Lucas.

Em tese, passou a ser possível, em sede de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim concluo, pois, a despeito de minha total discordância pessoal, sou forçado a reconhecer que o STF considerou inconstitucional a vedação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos trazida pelo art. 44 da nova Lei de Drogas. O leading case sobre o tema foi o HC 97.256/RS. Por força de tal decisão, a resolução n. 5, de 2012, do Senado Federal, publicada em 16 de fevereiro de 2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Posteriormente, em mais um de seus controversos julgados, o STF também considerou afastada a natureza hedionda do delito em testilha quando computada a causa de diminuição de pena acima ponderada (HC 118533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, 23.6.2016), de modo a excluir a incidência do art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes

Hediondos.

Assentadas tais premissas (ainda que a contragosto deste sentenciante), entendo que o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade mais adequado é o semiaberto, à luz da quantidade da exprobração e levando em conta a ausência de antecedentes criminais desabonadores.

O quantum dos escarmentos impede a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos para ambos os réus, saliento.

4. Ante o exposto:

A) declaro o réu GEOVANI OLIVEIRA SANTOS incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06, e o condeno à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

B) declaro o réu LUCAS DOS SANTOS SANTANA incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06, e o condeno à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

5. O réu Geovani, que respondeu ao feito preso, assim deve permanecer, pois seu acautelamento anterior, por óbvio, foi revigorado com a prolação desta sentença condenatória que o exprobrou a iniciar a pena em regime fechado.

Seria um manifesto contrassenso, aliás, que respondendo ao feito preso o réu condenado a regime inicial fechado pudesse ser posto em liberdade após a sentença recorrível. Outro não é o posicionamento do STJ em hipóteses do gênero:

“O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade”

(AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Quanto ao réu Lucas, expeça-se alvará de soltura clausulado.

6. Determino, ainda, o perdimento do numerário apreendido, ante as fortes evidências de se tratar de dinheiro fruto da traficância espúria (art. 63, par. 1º, Lei de Drogas). Oficie-se.

7. Após o trânsito em julgado desta, lancem-se os nomes dos apenados no rol dos culpados.

8. Custas na forma da legislação estadual.

9. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

10. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA